

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด บุรีรัมย์
นาย สิ้น จำปา สี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

โจทก์ฟ้องจำเลยข้อมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพา อาวุธปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางนำสืบโจทก์ไม่มี อาวุธปืนที่ฟ้องเป็นของกลาง แสดงต่อศาลว่าเป็นอาวุธปืนที่จำเลย ไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง ทั้งไม่ได้ นำสืบให้เห็นว่า จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง และพาอาวุธปืน ติดตัว ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า อาวุธปืนดังกล่าวจำเลยมีไว้ใน ครอบครองและพา ติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2533 เวลากลางวัน จำเลยมีอาวุธปืนเก็บ ยาวชนิดประกอบขึ้นเองซึ่งใช้ยิงได้ 1 กระบอก ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนประจำ อาวุธปืนของเจ้าพนักงานประทับไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนาย ทะเบียนท้องที่และพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปตามทางสาธารณะในหมู่บ้านโดยเปิด เผย ไม่มีเหตุสมควรและไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ทั้งไม่ใช่กรณีต้องมี ติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์ แล้วใช้อาวุธปืนดังกล่าว ยิงนายหนูพวนหรือขอด เพื่อนอก ผู้เสียหาย 1 นัด โดยเจตนาฆ่าแต่การกระทำนั้น ไม่บรรลุผล เนื่องจากดินปืนที่บรรจุอยู่ในอาวุธปืนไม่ระเบิด จึงไม่ทำให้ลูกกระสุนปืน

ระเบิดออกไปถูกผู้เสียหายผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่ตำบลโนน
ดินแดง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 371, 288, 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288 ประกอบด้วยมาตรา 81, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ
ระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8
ทวิวรรคหนึ่งและวรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2519) ข้อ 3, 6, 7 เป็นการกระทำความผิดต่างกัน ให้ลงโทษ
ทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายาม
ฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 81 จำคุก 2 ปี
ฐานมีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีได้ตามกฎหมายไว้ในครอบครองโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7, 72 วรรคสาม จำคุก 6 เดือน
ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและโดยเปิดเผย
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง, 72 ทวิ
วรรคสอง เป็นกรรมเดียวกับฐานพาอาวุธไปในหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยเปิดเผย
และไม่มีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ให้ลงโทษตามพระราช
บัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน รวมลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ฐานพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านปรับ 100 บาท หากไม่ชำระค่าปรับให้ กักขังแทนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 และให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับ ข้อหาตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม, 8 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง, 72 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นที่ยึดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ว่า จำเลยใช้อาวุธปืนแก้ปยาวยิงผู้เสียหาย ซึ่งมีความหมายต่อไปว่าจำเลยได้พาอาวุธ ปืนดังกล่าวไปในเมืองหรือหมู่บ้านด้วย คดีมีประเด็นมาสู่ศาลฎีกาว่าจำเลยมีอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนของผู้อื่นไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามฟ้องของโจทก์หรือไม่ คดีนี้โจทก์ไม่มีอาวุธปืนที่ฟ้องเป็นของกลางแสดงต่อศาล ว่าไม่เป็นอาวุธปืนที่จำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีไว้ในครอบครอง ทั้งโจทก์ไม่ได้นำสืบ ให้เห็นว่าจำเลยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนติดตัว ดังนี้ ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า อาวุธปืนดังกล่าวจำเลยมีไว้ในครอบครอง และพาอาวุธ ปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยจึงมิได้กระทำความผิดตามที่โจทก์ฎีกาศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ไม่ลงโทษจำเลยสำหรับความผิดฐานนี้ชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้น บางครั้งก็ไปเกี่ยวพันกับความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดหลัก เช่น ใช้ปืนยิงคนตาย ปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืน เป็นต้น ส่วนที่เป็นความผิดโดยตรงหรือเฉพาะเรื่องก็คือกรณีความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 โดยฐานความผิดที่จะพบเห็นได้บ่อย คือ ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 7,8,8 ทวิ อย่างไรก็ตามในความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนก็มีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับความผิดฐานพาอาวุธปืนในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะและความผิดฐานยิงปืนโดยใช้เหตุในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371,376 อีกด้วย ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงมีปัญหามากพอสมควรในด้านการวินิจฉัยข้อเท็จจริง การปรับบท และการเรียบเรียงถ้อยคำสำนวนในส่วนของการพิพากษา ปัญหาเกี่ยวกับการนำสืบนั้น เมื่อความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนไปเกี่ยวพันกับความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดหลัก ดังนั้นการนำสืบจึงอาจจะเน้นหนักไปที่ความผิดหลัก จนบางครั้งโจทก์อาจจะละเลยไม่ได้ นำสืบให้ครบถ้วนองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ ซึ่งโจทก์ต้องมีภาระการพิสูจน์ให้ได้ความครบองค์ประกอบความผิดมิฉะนั้นก็ลงโทษจำเลยในความผิดฐานดังกล่าวไม่ได้ (ฎีกาที่5177/2530) โดยไม่ต้องไปคำนึงถึงผลแห่งการวินิจฉัยความผิดหลักเช่น กรณีได้ความว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริง ปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนจริง ก็ได้หมายความว่าลงโทษฐานมีอาวุธปืน หรือพาอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตไปด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งไม่ใช้การอาศัยพยานหลักฐานในความผิด

หลักโยงโยไปได้ถึงเพียงนั้นกรณีต่างกับการที่จับจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนถึง 8 กระบอก แม้ไม่มีพยานหลักฐานซึ่งแสดงว่าจำเลยมีอาวุธปืนเหล่านั้นไว้เพื่อการค้าแต่การมีอาวุธปืนถึง 8 กระบอกนั้นแสดงอยู่ในตัวว่าน่าจะมีใช้ไว้เพื่อป้องกันทรัพย์สิน หากแต่เป็นการมีไว้เพื่อการค้า จำเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพื่อการค้า (ฎีกาที่ 3321/2531) ปัญหาว่าจะพิสูจน์อย่างไรนั้น คงเป็นเรื่องที่จำกัดบรรทัดฐานในรายละเอียดได้ยาก จึงต้องยึดหลักการพิสูจน์ในคดีอาญาที่ว่า โจทก์ต้องพิสูจน์โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดจริงอย่างไรก็ตามหากศึกษาตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วปัญหาเกี่ยวกับการนำสืบในคดีอาวุธปืน อาจจะต้องข้อสังเกตได้ดังนี้ 1. การนำสืบเป็นภาระของโจทก์เป็นหลัก หากโจทก์ไม่สืบหรือสืบไม่ได้ แม้จำเลยจะไม่นำสืบปฏิเสธ ก็ลงโทษจำเลยไม่ได้ (ฎีกาที่ 795/2504 ประชุมใหญ่, 2778/2525, 5177/2530) 2. กรณีโจทก์นำสืบได้ความเพียงจากการที่จำเลยตอบคำถามค้านของโจทก์ว่าไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีหรือพาอาวุธปืนมาก่อนนั้นเพียงแค่นี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่าไม่พอฟังลงโทษจำเลยได้ ซึ่งผู้บันทึกก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ได้นำสืบหรือพิสูจน์ให้ได้ว่าความจริงเป็นเพียงลักษณะการแสวงหาพยานหลักฐานจากการที่จำเลยตอบคำถามค้านของโจทก์เท่านั้น ไม่มีพยานหลักฐานอื่นเป็นหลักเพื่อให้ข้อเท็จจริงที่ได้จากการถามค้านเข้าไปเชื่อมได้ ฎีกาที่ 858/2532 คดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าจำเลยกระทำผิดตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อโจทก์มิได้สืบให้เห็นว่าจำเลยมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแม้จะฟังได้ว่าจำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหายและในชั้นสืบพยานจำเลย จำเลยจะตอบคำถามค้านของโจทก์ว่าจำเลยไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีหรือพาอาวุธปืนมาก่อน ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกระทำผิดฐานมีและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงลงโทษจำเลยไม่ได้ ฎีกาที่ 3674/2532 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนไว้ในครอบครอง และพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะได้ความจากคำเบิกความของจำเลยตอบคำถามค้านของโจทก์ว่าจำเลยไม่เคยได้รับ

อนุญาตจากทางราชการให้มีและพาอาวุธปืน ก็ถือไม่ได้ว่าโจทก์นำสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว เพราะในการพิจารณาคดีอาญาโจทก์ก็มีหน้าที่นำสืบให้ฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิด ทั้งโจทก์ก็ไม่ได้อาวุธปืนที่จำเลยใช้ขู่ชิงทรัพย์เป็นของกลาง และไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่พิสูจน์ให้เห็นว่าอาวุธปืนดังกล่าวไม่มีหมายเลขทะเบียน จึงลงโทษจำเลยในความผิดทั้งสองฐานนี้ไม่ได้ 3. กรณีที่โจทก์สืบไม่ได้ข้อเท็จจริงอันจะเป็นองค์ประกอบความผิดฐานมีและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงในคดีต้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371,376 และโจทก์ได้บรรยายฟ้องและมีคำขอท้ายฟ้องมาด้วย ศาลก็พิพากษาปรับบทตามความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาได้ ฎีกาที่ 4092/2530 แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตาย แต่การที่ศาลจะลงโทษจำเลยในข้อหา มีและพาอาวุธปืนฯ โดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ นั้น โจทก์มีหน้าที่นำสืบให้เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดจริง เมื่อโจทก์มิได้นำสืบว่าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างไร ปืนที่จำเลยใช้กระทำความผิดเป็นปืนมีทะเบียนหรือไม่อาจทราบได้ จึงลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้ แต่ปรากฏว่าบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้าน ศาลย่อมลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ได้ ฎีกาที่ 5982/2530 ในความผิดฐานพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่าจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว เมื่อโจทก์ไม่นำสืบก็ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิวรรคแรก ประกอบมาตรา 72 ทวิ วรรคสองไม่ได้คงลงโทษได้เพียงฐานพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 4. เหตุผลที่ว่า โจทก์ไม่ได้อาวุธปืนของกลางเข้ามาในคดีด้วยนั้น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ศาลฎีกาหยิบยกขึ้นมาเป็นข้อดำเนินโจทก์ในกรณีที่การนำสืบข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ แต่เหตุดังกล่าวมิใช่เหตุผลที่เป็นข้อยุติตายตัวว่า หากไม่ได้ปืนของกลางเข้ามาในคดีแล้วจะถือว่าการนำสืบฟังไม่ได้ เหตุผลที่แท้จริงคงอยู่ที่ว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีความหนักแน่นพอหรือไม่เท่านั้น

โจทก์อาจนำสืบพนักงานสอบสวนผู้เคยสอบคำให้การจำเลยและให้การในชั้นสอบสวนว่าไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีและพาอาวุธปืนติดตัว หรือนำสืบนายทะเบียน เป็นต้น ฎีกาที่ 5509/2530 จำเลยกับพวกร่วมกันมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนดังกล่าวไปใช้ยิงผู้ตายและผู้เสียหายในทางสาธารณะ แม้โจทก์ไม่ได้อาวุธปืนดังกล่าวมาเป็นของกลาง แต่ตามคำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยรับว่าไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อน ซึ่งมีพนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันและจำเลยก็มีได้ถามค้านหรือนำสืบหักล้างแต่อย่างใด ย่อมฟังได้ว่า จำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ด้วยว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับตามที่โจทก์ฟ้อง จึงลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในความครอบครองไม่ได้ คงลงโทษได้แต่เฉพาะข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ฎีกาที่ 5881/2530 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยใช้อาวุธปืนที่ติดตัวไปตีทำร้ายผู้เสียหายแม้จะไม่ได้อาวุธปืนมาเป็นของกลาง แต่จำเลยให้การในชั้นสอบสวนรับว่าไม่ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจึงลงโทษจำเลยในข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ แต่ตามฟ้องของโจทก์มิได้ระบุว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีและพาไปเป็นอาวุธปืนที่มีได้รับอนุญาตให้มีตามกฎหมาย ทั้งโจทก์ก็นำสืบไม่ได้เช่นนั้น จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลยว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีตามกฎหมาย 5. เมื่อมีการฟังข้อเท็จจริงตามที่นำสืบได้ตามข้อ 4 แล้ว แต่จะลงโทษจำเลยได้เพียงใดนั้นต้องกลับมาดูการตั้งรูปเรื่องฟ้องของโจทก์เป็นสำคัญ ดังกรณีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่องที่กล่าวมาแล้วในข้อ 4 ซึ่งอาจจะฟ้องการได้ดังนี้ ก. กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาแรก โจทก์ตั้งรูปเรื่องคำฟ้องเกี่ยวกับความผิดฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า อาวุธปืนที่มีไว้เป็นอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ ข้อเท็จจริงที่โจทก์

นำสืบได้ฟังได้เพียงว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่อาจฟังต่อไปได้ด้วยว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายของเจ้าพนักงานประทับไว้ตามที่โจทก์ฟ้องผลก็คือลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไม่ได้ คงลงโทษได้แต่เพียงฐานพาอาวุธปืน ข. กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่ 2 เป็นเรื่องโจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต มิได้ระบุว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้เป็นอาวุธปืนที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีตามกฎหมาย และโจทก์ก็นำสืบไม่ได้ว่า เป็นอาวุธปืนที่มีได้รับอนุญาตให้มีตามกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ต้องฟังเป็นคุณว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้เป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายแล้วและลงโทษตาม มาตรา 7,72 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ได้ เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วจะเห็นได้ว่า กรณีแรกตั้งรูปเรื่องฟ้องในลักษณะอาวุธปืนเถื่อน คือ ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายของเจ้าพนักงานประทับไว้สืบไม่ได้ก็ลงไม่ได้ ส่วนกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่ 2 ไม่ได้ตั้งรูปเรื่องคำพิพากษาว่าเป็นปืนเถื่อนก็ลงโทษได้ในลักษณะปืนที่มีทะเบียนแต่ใช้ผิดมือ ซึ่งมีลักษณะเงื่อนไขที่เกิดผลแตกต่างกันมากพอสมควรทั้งนี้ก็คงเป็นผลมาจากการตั้งรูปเรื่องคำฟ้อง ฟ้องอย่างไรก็ต้องได้ความตามฟ้องจึงจะลงโทษได้ เพื่อให้การศึกษาเป็นไปโดยละเอียดจึงขอสรุปข้อเท็จจริงของคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกัน ดังนี้ ฎีกาที่ 5509/2530 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกับพวกอีก 2 คนซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมีอาวุธปืน 3 กระบอกซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้ในครอบครอง และพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วร่วมกันใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสและนายขวัญชัยนาควรี ตาย โดยมีเจตนาฆ่า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,80,83,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ นาย

จำลอง นาควรีบิดาของนายขวัญนาควรี ผู้ตายร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ศาลชั้นต้นอนุญาต จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80,83,91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72ทวิ ลงโทษฐานพยายามฆ่าจำคุก 10 ปี ฐานฆ่าผู้อื่นจำคุก 20 ปี ฐานมีอาวุธปืน จำคุก 2 ปี ฐานพาอาวุธปืนจำคุก 1 ปี รวมจำคุก 33 ปีของกลางริบ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในข้อหา มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะตามฟ้องคงจำคุกฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นรวม 30 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนดังกล่าวไปใช้ยิงผู้ตายและผู้เสียหายในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางสาธารณะ แต่โจทก์ไม่ได้อาวุธปืนดังกล่าวมาเป็นของกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยให้การรับในชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การ เอกสารหมาย จ.4 ว่า จำเลยไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนมาก่อน โดยโจทก์มีร้อยตำรวจโทสาครบุไทยพนักงานสอบสวนมาเบิกความยืนยันว่า จำเลยให้การรับตามบันทึกคำให้การดังกล่าวซึ่งในข้อนี้จำเลยก็มีได้ถามค้านหรือนำสืบหักล้างแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าจำเลยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ข้อเท็จจริงยังไม่อาจฟังได้ว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับตามที่โจทก์ฟ้อง ฉะนั้นจึงลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ในความครอบครองตามที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ คงลงโทษได้แต่เฉพาะข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เท่านั้น พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ จำคุก 1 ปี รวมโทษฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นที่ศาลอุทธรณ์กำหนดไว้

30 ปี แล้ว เป็นจำคุก 31 ปีนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกา ที่ 5881/2530 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้ใช้ด้ามปืนตีทำร้ายร่างกายพลทหารสำราญนาย ศักดิ์ชัย เป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับอันตรายแก่กายและใช้กำลังชกต่อยนายไสว ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กาย กับจำเลยมีอาวุธปืนพกสั้นพร้อมกระสุนโดยไม่ได้รับ อนุญาตและพาอาวุธปืนดังกล่าวไปในที่สาธารณะ จัดให้มีการวิ่งเร่ฉลองงานบวช โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวไป และไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควร แก่พฤติการณ์ และจำเลยได้ยิงปืนที่บริเวณหมู่บ้านและที่ชุมนุม 1 นัดโดยไม่มีเหตุ อันสมควร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295,371,376,91 พระ ราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้น พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 จำคุก 1 ปี ลง โทษให้หนึ่งในสี่ตามมาตรา 78 คงจำคุก 9 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก โจทก์และจำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ ปืนฯ มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ลงโทษตาม มาตรา 7,72 จำคุก 1 ปี ลงโทษตามมาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ที่สุด จำคุก 6 เดือน รวมกับโทษฐานทำร้ายร่างกายเป็นจำคุก 1 ปี 15 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า จำเลยกระทำผิดฐานมีอาวุธปืนและพาอาวุธปืนโดยไม่ ได้รับอนุญาตตามฟ้องหรือไม่ และฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้ใช้อาวุธปืนที่พกติดตัว มาตีทำร้ายพลทหารสำราญและนายศักดิ์ชัย แม้จะไม่ได้อาวุธปืนที่จำเลยใช้ตีผู้เสีย หายมาเป็นของกลางก็ตาม แต่จำเลยก็ให้การในชั้นสอบสวนรับว่าจำเลยไม่ได้รับ อนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ซึ่งเจือสมคำฟ้องของโจทก์ทั้งพยานโจทก์ที่น่าสืบก็ฟังได้ ว่าจำเลยได้ใช้อาวุธปืนที่ติดตัวไปตีทำร้ายผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยย่อมเป็น ความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยจึง ลงโทษจำเลยในความผิดทั้งสองฐานดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตามในฟ้องโจทก์มิได้

ระบุว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีและพาไปเป็นอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีตามกฎหมายหรือไม่ จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลยว่า อาวุธปืนที่จำเลยมีเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคสามเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงไม่ชัดเจนศาลฎีกาเห็นสมควรระบวรคดีด้วยพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 7,72 วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ได้มีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้วินิจฉัยในลักษณะเดินตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 588/2531 แม้จะเป็นกรณีโจทก์ตั้งรูปเรื่องในฟ้องว่าเป็นอาวุธปืนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานประทับไว้เหมือนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5509/2530 ก็ตาม ดังตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ฎีกาที่ 2951/2531 โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นเลยว่าอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนที่มีทะเบียนหรือไม่มีทะเบียนดังที่โจทก์ฟ้อง ทั้งเจ้าพนักงานตำรวจก็ได้ยึดอาวุธปืนดังกล่าวมาเป็นของกลาง จึงต้องฟังให้เป็นคุณแก่จำเลยว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสามเท่านั้น ฎีกาที่ 2172/2534 ในข้อหาไม้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พยานโจทก์เบิกความว่าเห็นจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายและได้ความจากพนักงานสอบสวนว่า ในชั้นสอบสวนได้แจ้งข้อหาว่าจำเลยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และสอบถามจำเลย ปรากฏว่าจำเลยไม่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน จำเลยมิได้นำสืบหักล้างแต่กลับเบิกความตอบคำถามค้านเจือสมว่า จำเลยไม่เคยมีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและไม่มีใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว จึงถือว่าโจทก์ได้นำสืบถึงข้อหานี้แล้ว และแม้ไม่ได้

อาวุธปืนมาเป็นของกลางยืนยัน พยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวก็เพียงพอฟัง
ลงโทษจำเลยฐานนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อโจทก์นำสืบไม่ได้ว่า อาวุธปืนดังกล่าว
เป็นอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีตามกฎหมายหรือไม่จึงต้องฟังเป็นคุณแก่จำเลย
ว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีเป็นอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้ตาม
กฎหมายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 7,72 วรรคสาม ฎีกาที่
2475/2534 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานมีอาวุธปืนไม่ปรากฏหลักฐานใบ
อนุญาตให้มีและใช้จากนายทะเบียนและกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพาอาวุธปืน
ติดตัวไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยยื่นคำให้การมีใจความว่า จำเลยขอ
ให้การรับสารภาพความจริง อาวุธปืนตามฟ้องมีหมายเลขทะเบียน แต่เมื่อพนักงาน
สอบสวนส่งไปตรวจพิสูจน์ ปรากฏว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากทะเบียนอาวุธ
ปืนชำรุดหากสามารถตรวจสอบได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่จำเลย ขอให้ศาลรอกการ
ลงโทษด้วยศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่าจำเลยยื่นคำให้การรับสารภาพ
ศาลสอบแล้วจำเลยยืนยันให้การตามนี้ โจทก์จำเลยไม่สืบพยานเช่นนี้ คำให้การของ
จำเลยดังกล่าวเป็นการปฏิเสธว่าอาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาไปโดยไม่
ได้รับอนุญาตนั้นเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน เมื่อโจทก์ไม่สืบพยาน ต้องฟังข้อเท็จจริงว่า
อาวุธปืนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองและพาไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นอาวุธปืนมี
ทะเบียนของผู้อื่น จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 วรรคสาม
และมาตรา 8 ทวิ วรรคสองเท่านั้น. สุพิศปราณีตพลกรัง.